

1500830-06.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIZ MARCONDES PONTES

Comarca: Capivari

Foro: Foro de Capivari

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... rapaz; que confessou informalmente o tráfico, mas não estava traficando e que confessou apenas para não prejudicar a sua mãe.

A versão do réu está isolada no conjunto probatório, inexistindo provas que a sustentem. Ademais, considerando-se isoladamente a versão apresentada por ele, ficou confessado o crime de tráfico, já que informou que guardava drogas consigo como um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capivari

Foro de Capivari

2ª Vara

Rua Dr. João Adolfo Stein, 171, Capivari - SP - cep 13360-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500830-06.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500830-06.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS CARLOS IVANHA NETO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ MARCONDES PONTES

Vistos.

LUÍS CARLOS IVANHA NETO foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), porque, segundo narrou a denúncia, o réu, no dia 24 de maio de 2021, por volta das 21h00, na rua Machado de Assis n. 33, nesta cidade de Capivari, trazia consigo, para fins de comercialização, 61 papелotes de maconha e 59 microtubos contendo cocaína, substâncias estas entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (laudo pericial as fls. 19/23).

A denúncia foi oferecida em 27/05/2021 (fls. 80/81) e recebida em 28/05/2021 (fls. 83/85).

Citado em 20/06/2021 (fls. 93), o réu apresentou sua resposta à acusação à fls. 127/141.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas, uma informante e, ao final, o réu foi interrogado.

Em seguida, as partes se manifestaram, oralmente, em alegações finais.

É o relatório. Passo a fundamentar.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não havendo

quaisquer preliminares alegadas pela Defesa ou pelo Ministério Público, passo, pois, a conhecer diretamente do mérito.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitativa se encontra devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, boletim de ocorrência de fls. 09/14, auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, laudo de constatação de fls. 19/23 e laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 264/266.

Destaco que, conforme constou no referido auto de exibição, foram apreendidos os seguintes objetos: (i) um telefone celular; (ii) um porta-lápis; (iii) um isqueiro; (iv) R\$ 10,15 em espécie; (v) 61 papелotes contendo maconha (86,7 gramas); (vi) 59 microtubos contendo cocaína (14,7 gramas). Conforme ficou consignado no laudo definitivo, ficou confirmada a natureza das substâncias apreendidas, tratando-se de drogas de uso proscrito no país.

A autoria também restou devidamente comprovada nos autos.

Ouvido em juízo como testemunha, o GCM Diogo narrou, em breve síntese, que no dia dos fatos estava em patrulhamento de rotina, em local conhecido como ponto de venda de drogas; que, no momento em que adentrou na rua, avistou o réu entregando algo para o motorista de um veículo; que, em razão disso, o réu foi abordado e, na sua posse, foram encontradas as drogas apreendidas; que o réu confessou informalmente a traficância; que não se recorda do nome da via pública em que os fatos se deram; que a abordagem se deu defronte à casa do réu; que a localidade era bastante conhecida como ponto de venda de drogas; que dias antes havia ocorrido uma prisão de um indivíduo com drogas também na mesma localidade; que, em dia anterior, não sabendo precisar ao certo a exata data, houve a prisão de dois indivíduos, um deles maior e outro menor, sendo que um deles foi preso no interior da casa do réu; que o depoente não participou de tal diligência e o que sabe foi de ouvir dizer; que ficou sabendo que os dois indivíduos foram avistados na via pública e correram para o interior da residência do réu; que, no dia da prisão do réu, a mãe do réu se apresentou, mas não foi feita nenhuma busca no imóvel; que não sabe quem é Daniela Aparecida Camargo; que houve uma gravação feita pela GCM da diligência; que nunca teve qualquer problema pessoal com o réu; que estava distante do réu cerca de dez metros quando o avistou; que a diligência ocorreu no período noturno.

Ouvido em juízo como testemunha, a GCM Patrícia narrou versão similar àquela apresentada pela testemunha GCM Diogo. Acrescentou que não gravou a abordagem em si, pois passou a gravar os fatos quando a mãe do réu compareceu, assim como o réu.

Ouvida em juízo como informante por ser a mãe do réu, a Sra. Rosemeire narrou, em breve síntese, que, no dia dos fatos, a depoente estava trabalhando; que era por volta de umas 20h00min; que o réu já havia sido detido; que a depoente não conversou com os policiais; que o réu estava trabalhando em mecânica e de servente; que tinha conhecimento de que o réu estava usando maconha; que então ficou sabendo que ele estava usando cocaína.

Interrogado, o réu disse que, no dia 22 “tomou enquadro” na rua e foi perguntada qual era a sua idade; que foi ameaçado de ser preso; que, no dia 24, um veículo passou perto do depoente e perguntou qual era o endereço; que, logo em seguida, “tomou um enquadro” dos GCMs ouvidos como testemunhas; que o réu foi acompanhado até a sua casa; que os guardas perguntaram ao interrogando se ele tinha drogas; que o réu disse que tinha algumas porções para o seu consumo; que o depoente disse também que tinha drogas que estava guardando para um terceiro; que estava endividado e guardou a droga para um rapaz que iria pegar as drogas; que os guardas falaram que iriam esperar o rapaz; que confessou informalmente o tráfico, mas não estava traficando e que confessou apenas para não prejudicar a sua mãe.

A versão do réu está isolada no conjunto probatório, inexistindo provas que a sustentem. Ademais, considerando-se isoladamente a versão apresentada por ele, ficou confessado o crime de tráfico, já que informou que guardava drogas consigo como um serviço prestado a terceiro, porque estava endividado.

Em suma, à luz da versão do réu, ficou comprovado o tráfico de drogas.

Ocorre que a versão do réu é contraditada pela versão das testemunhas. Estas, por sua vez, apresentaram em juízo versão firme e consistente, sem qualquer nota de contradição ou indício de que, qualquer um deles, tenha faltado com a verdade.

Cumpra salientar que o depoimento dos guardas civis, assim como de policiais em geral é válido como outro qualquer, pois o artigo 202 do Código de Processo Penal dispõe que qualquer pessoa pode ser testemunha, não trazendo qualquer distinção entre policial e não policial. Além disso, o pensamento no sentido de que os testemunhos prestados por policiais devem ser recebidos com cautela, apenas e tão somente pelo simples fato de que tais agentes pretenderiam justificar a legalidade e legitimidade de suas ações, vem a muito sendo rebatida, devendo, assim, ser levados em conta com a credibilidade que as circunstâncias do caso concreto permitem lhe atribuir. Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. PENAL. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA: EXAME. I. - O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento. II. - Não é admissível, no processo de habeas corpus, o exame aprofundado da prova. III. - H.C. indeferido". (STF - Rel. Min. Marco Aurélio - J. em 04/08/1998 - 2ª. Turma - HC 76557 / RJ - Rio de Janeiro).

Entendo que o testemunho de policiais não merece maior ou menor valor pelo simples fato de integrarem o sistema de segurança pública estatal. Entender que todo testemunho prestado policial é verdadeiro é tão equivocado quanto entender que todo testemunho prestado policial é falso. Os depoimentos devem ser valorados a partir de sua consistência, coerência e das circunstâncias fáticas vivenciadas pelo depoente.

E, nessa linha de raciocínio, não há qualquer explicação plausível para as testemunhas acusarem injustamente o réu, pois não possuem qualquer desavença anterior contra ele. O pensamento razoável leva a crer que um indivíduo, em sua consciência, jamais acusaria outro da prática de delito sem possuir motivações para acusá-lo. Sendo assim, todo o argumento que vise a impugnar suas palavras deve ser recebido com extrema cautela e, na maior parte das vezes, será mero subterfúgio da defesa pela absolvição por falta de provas. E mais, se o próprio acusado, ao ser interrogado, nada deduziu quanto a eventual restrição em face das testemunhas, por consequência não há razão para desacreditá-las.

Conclui-se, portanto, que, no presente caso, a prova testemunhal produzida, em conjunto com os demais elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação do réu. Como dito, a palavra dos policiais, tendo em vista a ausência de motivo para que ela seja desacreditada, tendo sido apresentada de forma consistente, coerente, crível e em conjunto com os demais elementos de prova existente nos autos, merece ser respaldada no presente caso.

Desta forma, tal como narrado pelos guardas civis, o réu foi avistado na via pública, em local conhecido como ponto de venda de drogas, entregando algo para o motorista de um veículo, que se evadiu dali logo em seguida. Destaco que o período era o noturno.

Consideradas estas circunstâncias, havia fundada suspeita da prática do crime de tráfico, já que a situação visualizada pelos guardas era típica de comércio ilícito - tratava-se de uma entrega de objeto em via pública, no período noturno, em local conhecido como ponto de venda de drogas. Evidentemente, justificada estava a abordagem dos guardas.

É válido esclarecer que entendo não haver qualquer vício na atuação dos Guardas Civis Municipais. Isso porque, o crime de tráfico de drogas é considerado um crime permanente, cujo estado de flagrância se perpetua no tempo. Assim, não há qualquer ilegalidade na atuação dos guardas que, visualizando uma situação de flagrante delito, agem para cessar a sua prática. Aliás, trata-se de conduta que homenageia a função pública que exercem, na medida em que, a despeito de não estar inserida no âmbito da função precípua que exercem (proteção dos bens, serviços e instalações do município), os guardas não se omitiram diante da prática do crime que estava sendo cometido às suas vistas. Ademais, à luz do art. 301 do Código de Processo Penal, na medida em que os agentes da Guarda Municipal também podem ser incluídos no conceito de "autoridades policiais e seus agentes", estes possuem o dever legal de agir quando diante de um flagrante delito.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"Embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, §8º da Constituição da República, sendo o delito de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator (...) (STJ, HC 109.592-SP, 5ª Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 18.2.2010, Dje 29.3.2010).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. MEIOS ILÍCITOS. OBTENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CPP. INTELIGÊNCIA. 1. Qualquer um do povo pode prender quem se encontre em flagrante delito, não obstante a atribuição da Guarda Municipal atribuída pela Constituição (ex vi, art. 144, § 8º, da CRFB/1988), o que revela a legalidade da hipótese dos autos. Inteligência do art. 301 do CPP. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, 6ª Turma, AgInt no AREsp 950569, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 21/02/2017).

Prosseguindo.

Realizada a abordagem, na posse do réu foram encontradas as drogas apreendidas. A quantidade de drogas apreendida, por si só, é representativa do tráfico, porquanto foram apreendidos 61 papelotes de maconha e 59 microtubos contendo cocaína, incompatível com o mero uso, portanto. Deve-se destacar que o réu foi avistado comercializando drogas, como ficou comprovado após sua abordagem, o que inviabiliza qualquer desclassificação para o crime de porte de drogas para o consumo próprio.

Em suma, a condenação do réu se impõe.

Dosimetria da pena.

Conforme certidão de fl. 87, o réu é primário e não ostenta antecedentes. Ademais, conforme carteira de identidade de fl. 25, o réu era menor de 21 anos na data dos fatos.

A pena prevista para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 é de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atentando para o quanto disposto no art. 59 do Código Penal, à luz do critério de preponderância estabelecido pelo artigo 42 da Lei 11.343/2006, entendo que a reprovabilidade é comum à espécie, motivo pelo qual fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, embora presentes circunstâncias atenuantes, quais sejam, agente menor de 21 anos na data dos fatos, não é admissível reduzir-se a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."). Embora irrelevante, a confissão não deve ser acolhida, porquanto o réu apresentou versão não condizente com a realidade.

Não existem causas de aumento, porém incide a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois, não havendo prova contundente nos autos de que o réu se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, pode-se presumir que não se dedique, de forma permanente e habitual, à atividade criminosa de traficar drogas, reiteradamente, ou que seja integrante de organização criminosa, situação especial que exige prova cabal e não mera conjectura. Não havendo prova de que o réu integre organização criminosa ou se dedique de forma habitual a atividades criminosas, afastar-se a aplicação do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06 incorreria em grave violação ao ônus probatório do processo penal, prejudicando o réu de forma sobremaneira em razão de uma mera presunção, e não por um fato comprovado nos autos.

De fato, a quantidade de droga apreendida, por si só, não revela que o réu se trata de grande traficante, ou, ainda que pequeno traficante fosse, integra organização criminosa ou se dedica às atividades criminosas. Além disso, é primário, não possuindo antecedentes. Finalmente, não há sequer indício de que o réu integre organização criminosa ou que seja traficante profissional.

A alegação de que, pelo simples fato de trazer consigo drogas é indicativo de que ele integra organização criminosa ou se dedica às atividades criminosas representa presunção inadmissível no processo penal. Aliás, é conclusão que sequer se sustenta

do ponto de vista lógico, já que é logicamente possível (e porque não, corriqueiro), que o indivíduo pratique o tráfico de drogas de forma pontual em sua jornada. Se não há prova de que ele se dedica às atividades criminosas ou integre organização criminosa é direito subjetivo do condenado a redução de pena prevista no § 4º, art. 33, da Lei de Drogas.

Observo que, para fim de progressão e de concessão de outros benefícios, deverá ser observado que o crime praticado não é hediondo ou equiparado (STF, HC nº 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, J. 23/06/2016), de modo que a progressão poderá ser concedida com o cumprimento de um sexto da pena, o livramento condicional pode ser concedido com o desconto de um terço da pena, e pode haver a concessão de indulto e de comutação de penas ao acusado.

Dessa feita, diante de tal causa de diminuição de pena, legalmente estipulada em 1/6 a 2/3, entendo que, no caso, considerando que a quantidade de drogas não é expressiva, entendo pela aplicação do patamar máximo de redução, motivo pelo qual fixo a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Ausentes outras causas de diminuição ou de aumento de pena, torno-a definitiva.

Em respeito ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 1.052.700 (Tema 972), em que se fixou a seguinte tese "é inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal", considerando, portanto, os parâmetros fixados no art. 33, § 2º, do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Deixo de aplicar o art. 387, parágrafo segundo, CPP, isto é, computando o tempo de prisão provisória para a definição do regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que não há nos autos elementos que permitam a aferição da conduta carcerária do réu, de forma que ao juízo da execução é que cabe, assim que receber a guia de execução, provisória ou definitiva, avaliar a possibilidade de detração e progressão do réu a regime menos afilitivo.

Atento que o tráfico privilegiado não é hediondo ou equiparado (STF, HC nº 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, J. 23/06/2016), presentes os requisitos que autorizam a substituição da pena, nos termos do art. 44, § 2º do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade, cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação; e b) prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, a ser paga na forma estipulada pelo juízo da execução. A prestação de serviços à comunidade deverá ser cumprida junto a entidades assistenciais ou outros estabelecimentos congêneres (artigo 46, caput), à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho.

Decido.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR LUÍS CARLOS IVANHA NETO como incurso no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado segundo o INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática para Atualização de Débitos Judiciais do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo até o efetivo pagamento. Nos termos da fundamentação acima, a pena privativa de liberdade é substituída por: a) prestação de serviços à comunidade, cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação; e b) prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, a ser paga na forma estipulada pelo juízo da execução.

Diante quantidade de pena imposta, atento ao regime aberto para o início do cumprimento da pena, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.

Caso ainda não tenha sido realizada tal providência, nos termos do art. 50, §3º, da Lei 11.343/06, autorizo a destruição das drogas apreendidas, com a ressalva das amostras guardas para contraprova. Cópia digitalmente assinada da presente sentença valerá como ofício à autoridade policial.

Com o trânsito em julgado, nos termos do art. 525 das Normas de Serviço da

Corregedoria Geral de Justiça, fica desde já autorizada a destruição das amostras guardadas para contraprova, oficiando-se para tanto.

Nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, determino o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União (FUNAD). Com o trânsito em julgado, remeta-se à SENAD relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, o local em que se encontram e a entidade ou o órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente.

Condenação à taxa judiciária. Condene o(s) réu(s), na forma do art. 804 do Código de Processo Penal e da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º, ao pagamento da taxa judiciária, observado, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio, o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil ("Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.")

Expedição de certidão do Convênio OAB/DPE. Em caso de defesa patrocinada por meio do Convênio OAB/DPE, aguarde-se o decurso do prazo para interposição de recurso. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários (para pagamento de 100% do valor previsto na tabela). Na hipótese de interposição de recurso por qualquer uma das partes, expeça-se certidão de honorários, observando-se a seguinte regra do Convênio: "nos processos criminais de competência do Juízo singular, após a sentença condenatória ou absolutória com interposição de recurso por quaisquer das partes, 70% (setenta por cento) do valor previsto na tabela por ocasião da sentença e, os 30% (trinta por cento) restantes, após o trânsito em julgado do acórdão."

Expedição de guia de execução provisória. Interposto o recurso, em caso de réu(s) preso(s), expeça-se guia de execução provisória.

Após o trânsito em julgado, (a) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); (b) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (c) expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Capivari, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA